

1502178-36.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... DE TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE. TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO. 3. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO. ARTS. 35 E 37 DA LEI Nº

11.343/2006. AGENTE QUE EXERCE FUNÇÃO DE INFORMANTE DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DA QUAL PARTICIPA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.

DUPLA APENAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 4. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502178-36.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502178-36.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

SAMUEL DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

SAMUEL DA SILVA SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 21h17, na Rua Tilápia, 38, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava e trazia para entrega ao consumo de terceiros, 80 porções de maconha, 170 porções de cocaína e 37 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 23 de setembro de 2021 (fls. 36/38).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11/12), assim como o laudo de constatação (fls. 16/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 65/67).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 74/82). Em 11 de fevereiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 84).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) SAMUEL DA SILVA SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 22 de setembro de 2021, por volta das 21h17, na Rua Tilápia, 38, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava e trazia para entrega ao consumo de terceiros, 80 porções de maconha, 170 porções de cocaína e 37 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis municipais em patrulhamento suspeitaram do nervosismo do réu com a aproximação da viatura, realizaram a abordagem e sob a posse direta do réu encontraram uma porção de maconha e R\$65,00. Ao lado dele havia uma sacola com as outras drogas.

Concluída a instrução, entendo que o Ministério Público se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. A quantidade e diversidade de espécies de drogas envolvidas não permitem pensar em porte para uso próprio e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Moacir e Marcos declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, suspeitaram do comportamento do réu, abordaram-no e sob a posse dele encontraram apenas uma porção de droga, além de certa quantia de dinheiro em notas de pequeno valor. Na ocasião, o réu admitiu que estava atuando como "olheiro" do tráfico, a serviço de "Richard", que não estava no local.

Em juízo eles enfatizaram que não é factível a versão do réu de que ele estava atuando apenas como "olheiro", uma vez que estava sozinho, a porção de maconha que estava com ele era semelhante às outras porções da mesma droga que estavam na sacola e os "olheiros" nunca correm porque apenas avisam os comparsas que realmente estão traficantes.

Não bastassem as provas acima, é imperioso acrescentar que o réu não mostrou credibilidade alguma nas oportunidades em que foi ouvido. Por primeiro, noto que ele deu uma versão na polícia e outra em juízo. Naquela ele era "olheiro" ou campana e nesta mero usuário. Questionado sobre essa divergência, ele disse que nada falou na polícia e que apenas assinou uns papéis, o que, por si só, é estranho porque o inquérito policial é digital. Por segundo, confiro que ele afirmou peremptoriamente que nada falou e que nem sequer teve oportunidade de realmente ser interrogado. Questionado se falou aos policiais que tinha filhos, ele negou. Contudo, ao ser indagado sobre a informação que consta de seu interrogatório policial que tem 3 filhos, com as respectivas idades, ele voltou atrás para afirmar que talvez tenha dito sobre isso. Por terceiro, observo que ele explicou que estava com dinheiro que seu pai havia lhe dado, derivado de seus proventos. Mas não há uma prova sequer disso, malgrado ele pudesse comprovar isso, com maior ou menor poder de convencimento, respectivamente, com documentos ou testemunhos, mas sempre com grande facilidade.

A apreensão de vários tipos de droga em local próximo àquele em que estava o réu, a ausência de outras pessoas próximas a ele, a existência de dinheiro de origem não comprovada e as divergências do réu indicam que ele estava no local traficando.

Faço questão de ressaltar todos esses pontos não apenas para demonstrar que o réu praticou um crime, mas que realizou atos típicos de tráfico de drogas, não de mero informante, haja vista que ser "campana" pode caracterizar outro crime, conforme segue:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. DELITO DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESSUPOSIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ENVOLVIMENTO COM O GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNÇÃO INTERNA DE SENTINELA, FOGUETEIRO OU INFORMANTE. CONFIGURAÇÃO DE TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE. TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO.

3. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO. ARTS. 35 E 37 DA LEI Nº 11.343/2006. AGENTE QUE EXERCE FUNÇÃO DE INFORMANTE DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DA QUAL PARTICIPA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA APENAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 4. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 5.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA CASSAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006 E ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO.

(...)

2. A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante.

3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave.

De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem.

4. Além de o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o crime de associação nem sequer é equiparado a hediondo, não havendo se falar, portanto, em regime fechado decorrente de imposição legal.

Fixada a reprimenda no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias negativas, mostra-se adequada a aplicação do regime aberto, nos termos do que disciplina o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar a condenação pelo delito descrito no art. 37 da Lei nº 11.343/2006, mantendo apenas o édito condenatório pelo crime de associação, alterando-se, no mais, o regime de cumprimento da pena para o aberto."

(HC 224.849/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 287 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se a propósito, posicionamento do C. STJ sobre o tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 12/08/2021, nos autos 1502749-75.2019, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal de Carapicuíba, pela prática de tráfico de drogas (fl. 64). Em razão disso, exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 7 anos e 4 meses de reclusão.

Deixo de levar em conta a atenuante da confissão espontânea, como requerido pela defesa, pois o réu não confessou o tráfico nem na polícia nem em juízo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Em razão da reincidência, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 7 anos e 4 meses de reclusão. Preso desde 22 de setembro de 2021 o réu não tem direito à detração em sentença para alteração do regime inicial fixado porque o tempo de prisão provisória não corresponde à fração da pena que ele teria de cumprir para ter direito à progressão de regime.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Embora ele esteja preso desde a data do flagrante, ele ainda não completou nem mesmo 1/6 da pena, malgrado a progressão dependeria de percentual maior, de tal maneira que não há que se cogitar de levar em consideração a detração para fins de fixação de regime menos gravoso.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 733 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) SAMUEL DA SILVA SANTOS, como incurso(a) no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 733 (hum mil e) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

Defiro o pedido da defesa para conceder ao réu o benefício da justiça gratuita.

Anote-se.

P.R.I.C.

Barueri, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA